

<입문-제4장 행정행위.제3절 법적 구속 정도에 따른 구분>

**I. 개설**

**1. 법적 구속에 따른 구분의 중요성**

- 법적 구속의 정도에 따라 기속행위와 재량행위로 구별하는 것은 행정청의 처분에 대한 사법 심사의 범위를 결정하는 핵심 기준이며, 행정쟁송법에서 가장 중요한 쟁점 중 하나이다. 이 구별은 행정청이 법규에 구속되는 정도와 국민의 권리 구제 가능성을 직접적으로 연결한다.

**2. 행정법규에 대한 이해**

- 행정법규는 행정청에게 특정 행위를 할 의무를 부과(기속)하거나, 혹은 행위 여부나 내용을 선택할 수 있는 권한을 부여(재량)한다.

**(1) 기속성**

- 법규가 행정청의 의무를 명확히 정하고 선택의 여지를 주지 않는 경우이다.

**(2) 재량성**

- 법규가 행정청에게 행위의 여부, 시기, 내용 등을 스스로 판단할 수 있는 권한, 즉 재량을 부여하는 경우이다.

**3. 요건법규 · 효과법규와의 관련문제**

- 행정법규는 크게 요건 법규와 효과 법규로 구성된다.

**(1) 요건 법규**

- 행정청이 처분을 발동하기 위해 충족되어야 할 사실적 · 법적 조건을 규정한 부분이다.

**(2) 효과 법규**

- 요건이 충족되었을 때 행정청이 취해야 할 행위의 종류와 내용을 규정한 부분이다. 기속행위와 재량행위의 구별은 주로 효과 법규의 내용에 의해 결정된다. 즉, 요건이 충족되었을 때 '반드시 ... 하여야 한다'고 규정하면 기속행위가 되고, '... 할 수 있다' 또는 '... 할지 여부를 재량으로 한다'고 규정하면 재량행위가 된다.

**II. 기속행위**

**1. 의의**

- 기속행위란 행정청이 법규의 구체적인 내용과 취지에 엄격하게 구속되어 행위의 요건이 충족되면 법규가 정한 내용의 행위를 반드시 하여야 하는 행정행위를 말한다. 행정청의 판단 여지(선택의 자유)가 전혀 없다.

**2. 구별기준**

**(1) 문언기준**

- '하여야 한다', '의무를 진다', '강행한다' 등의 표현을 사용한다.

**(2) 법규의 성질 및 목적**

- 주로 국민의 권리 의무에 중대한 영향을 미치거나(예 : 조세 부과), 공익성이 강한 분야(예 : 보건, 환경 규제)에서, 법적 안정성 확보를 위해 기속행위로 해석되는 경향이 있다.

**3. 관련판례**

- 대법원은 행정청의 조세 부과 처분이나 건축 허가(건축법상 요건 충족 시)와 같이 국민의 권리 · 의무에 직접적인 영향을 미치고 법적 안정성이 강조되는 영역에서는 원칙적으로 기속행위로 해석한다.

**III. 재량행위**

**1. 의의**

- 재량행위란 행정청이 법규의 범위 내에서 행위의 발동 여부(선택 재량)나 행위의 내용(결정 재량)을 스스로 판단하여 결정할 수 있는 권한, 즉 재량을 가지는 행정행위를 말한다.

**2. 구별기준**

**(1) 문언적 기준**

- '... 할 수 있다', '... 할지 여부를 정한다', '필요하다고 인정하는 때' 등의 표현을 사용한다.

**(2) 법규의 성질 및 목적**

- 고도의 전문적 · 정책적 판단이 요구되는 영역(예 : 도시 계획, 허가 조건 설정)에서 행정의 탄력성과 효율성을 위해 재량행위로 해석되는 경향이 있다.

**(3) 행정행위의 효과**

**① 침익적 행위**

- 국민에게 불이익을 주는 침익적 행위는 일반적으로 재량의 여지가 넓게 인정되는 경우가 많다.

**② 수익적 행위**

- 국민에게 이익을 주는 수익적 행위 역시 공익과 사익의 형량을 위해 재량이 인정되는 경우가 많다.

**3. 관련판례**

- 국토 계획 및 이용에 관한 법률상 용도지역 변경 신청 거부나 공무원에 대한 징계 처분 등은 광범위한 공익적 판단이 요구되므로 재량행위로 본다.

**4. 재량행위 여부**

- 행정청에게 재량권이 부여된 경우, 그 재량권은 다음의 두 가지 차원으로 나뉜다.

**(1) 선택 재량 (행위 재량)**

- 행정청이 법규가 정한 요건이 충족되었을 때 해당 처분을 할 것인지 말 것인지를 선택할 수 있는 권한이다.

**(2) 결정 재량 (내용 재량)**

- 처분을 하기로 결정한 후, 그 처분의 내용, 시기, 조건 등을 선택할 수 있는 권한이다.

**5. 재량의 하자 일반**

- 재량행위는 행정청의 자유로운 선택권을 의미하지만, 이는 법의 범위 내에서 행사되어야 하며, 이를 위반할 경우 재량의 하자로 인해 위법해진다.

**(1) 재량권 일탈**

- 법이 정한 재량의 범위를 넘어서는 행위를 하는 경우이다. (예 : 법규가 정한 최고 형량을 초과하여 과징금을 부과) 이는 곧바로 위법이다.

**(2) 재량권 남용**

- 재량의 범위 내에 있지만, 재량의 목적에 위배되거나, 비례의 원칙, 평등의 원칙 등 행정법의 일반 원칙을 위반하여 부당하게 행사되는 경우이다.  
(예 : 사적인 감정으로 특정인에게 가혹한 처분을 부과) 이는 곧바로 위법이다.

**(3) 재량권 불행사 또는 해태**

- 행정청이 재량권이 있음에도 불구하고 이를 행사하지 않거나(불행사), 법이 정한 기간 내에 처분을 미루는 것(해태)을 말한다. 이는 거부 처분 또는 부작위의 문제로 연결될 수 있으며, 재량권이 부여된 행위를 하지 않기로 결정한 것이라면 재량의 남용으로서 위법해진다.

**Ⅳ. 각종 행정행위의 기속·재량행위 여부**

**1. 허가**

- 기속행위

**2. 하명**

- 원칙은 기속행위, 예외는 재량행위

**3. 면제**

- 특별한 구분 없음

**4. 특허**

- 재량행위

**5. 대리**

- 특별한 구분 없음

**6. 인가**

- 원칙은 재량행위, 예외는 기속행위

**7. 공증**

- 기속행위

**8. 통지**

- 기속행위

**9. 수리**

- 기속행위

**10. 확인**

- 기속행위

**V. 결론**

- 기속행위와 재량행위의 구별은 취소소송에서 본안 심리의 범위를 확정한다. 기속행위의 위법성은 법규 위반 여부에 대한 엄격한 심사(법률적 판단)로써 법원이 쉽게 판단할 수 있으나, 재량행위의 위법성은 오직 재량권의 일탈 또는 남용이 있었는지 여부만을 심사(재량 통제)할 수 있다. 법원은 재량행위에 대해 행정청의 판단을 존중하는 방향으로 심사하며, 이는 행정의 전문성과 효율성을 존중하는 사법의 소극적 태도를 보여준다.